

1501692-38.2022.8.26.0535
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS
Comarca: Santa Isabel
Foro: Foro de Santa Isabel
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 29/09/2022
... Código de Processo Penal.

Neste sentido: Tráfico de entorpecentes. Sentença desclassificando a conduta do réu para a prevista no artigo 28, da Lei nº 11.3343/06, sem a devida aplicação da pena. Ordem de remessa ao Juizado Especial Criminal. Hipótese em que a E. Magistrada, entendendo que a hipótese não era de tráfico, mas de uso, deveria ter aplicado a reprimenda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santa Isabel
Foro de Santa Isabel
1ª Vara
Pça, da Bandeira s/n - Centro - Santa Isabel, Santa Isabel-SP - cep 07500-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501692-38.2022.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501692-38.2022.8.26.0535
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2180248/2022 - DEL.POL.ARUJA, 25929789 - DEL.POL.ARUJA, 2180248 - DEL.POL.ARUJA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAFAEL MATOS FLAVIO
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Vistos.

O representante do Ministério Público propôs a presente ação penal condenatória em face de RAFAEL MATOS FLAVIO, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, em tese, nas circunstâncias de local e tempo descritas na denúncia (dia 04 de julho de 2022, em horário noturno, na Rua Japão, 10, Residencial São João, nesta cidade e Comarca de Santa Isabel), trazia consigo, para fornecimento de terceiros, 26 (vinte e seis) pedras, contendo 7,83g (sete gramas e oitenta e três decigramas) de

cocaína em forma de crack, 16 (dezesesseis) porções, contendo 32,40g (trinta e dois gramas e quarenta decigramas) de maconha e 61 (sessenta e um) supositórios, contendo 18,20g (dezoito gramas e vinte decigramas) de cocaína, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica.

Oferecida a denúncia e, não tendo sido vislumbradas hipóteses que levassem à rejeição liminar, foi determinado o processamento da ação penal (fls. 67). O réu foi devidamente notificado, tendo sido apresentada, por sua defesa, resposta à acusação (fls. 91/93). A denúncia, então, foi formalmente recebida e determinada sua citação (fls. 100).

No curso da instrução, realizada nesta data, colheu-se depoimento das testemunhas policiais e ao final foi o réu interrogado.

O Ministério Público, em debates, pugnou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A defesa do réu, em debates, pugnou pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, formulou requerimentos destinados a mitigar o rigor de eventual reprimenda.

Eis, em síntese, o relatório.
Fundamento e decido.

O pedido condenatório formulado pelo i. representante do Ministério Público é parcialmente procedente.

O auto de exibição e apreensão que instruiu o auto de prisão em flagrante dá conta da apreensão da substância entorpecente descrita na denúncia. As substâncias foram submetidas a exame preliminar de constatação, cujo laudo também foi juntado aos autos, de modo que constatada sua natureza. A apuração preliminar foi confirmada com o a realização do exame químico toxicológico (fls. 115/117). Quanto à autoria delitiva, tem-se a prova oral colhida em juízo.

O policial Ednaldo Barbosa Santana, em juízo, narrou que estavam em outra abordagem quando avistaram o acusado encostado em um muro. O acusado, ao perceber a presença policial, começou a andar. Foi então abordado pelo policial Moriguchi. Este encontrou entorpecente com o acusado. Posteriormente, em diligência pelo local, encontraram sacola contendo o restante do entorpecente. Após o encontro da sacola, o acusado confessou informalmente os fatos. Não conheciam o acusado antes da abordagem. A sacola estava mais ou menos no local em que o acusado estava, porém, o companheiro do depoente sabe informar melhor. O local é bastante conhecido pela traficância.

Edmar Moriguchi, policial ouvido em juízo, corroborou o depoimento de seu colega. Destacou que Rafael tentou se evadir, em passo acelerado, ao visualizar a viatura. Abordado, apenas havia um pino de cocaína com o acusado. Em diligência, localizaram sacola com maior quantidade de entorpecente. Após o encontro, o acusado confessou informalmente os fatos. No local, somente havia o acusado e outro indivíduo com quem nada de ilícito foi encontrado. Próximo ao local de encontro do entorpecente, somente estava o acusado. Os dois indivíduos não estavam próximos um do outro. O acusado estava encontrado em um muro. Neste havia um portão de ferro todo aberto. O entorpecente estava escondido neste portão. Em princípio, não poderia afirmar que a sacola era do acusado, mas este confessou. O pino encontrado no bolso do acusado era igual ao encontrado na sacola.

Quando do interrogatório judicial, afirmou que no dia dos fatos tinha brigado com familiares, de modo que estava revoltado. Foi ao local dos fatos apenas para comprar entorpecentes. Chamou taxi por aplicativo. Estava há cinco minutos no local, encostado em um muro. Tentou se evadir porque tinha pino de cocaína em seu bolso. Afirmou que estava no local apenas para uso de entorpecentes. Encontraram o

entorpecente próximo do outro indivíduo abordado, e não do acusado. O acusado estava há apenas um mês em liberdade, tendo antecedentes por receptação. É usuário de droga há bastante tempo. Trabalha em um lava rápido em Arujá. Em momento algum assumiu a propriedade dos entorpecentes. Foi abordado pelos policiais em outras oportunidades. Não sabe dizer porque os policiais disseram que o entorpecente estava próximo do acusado.

Em que pese a comprovação da natureza da substância apreendida e localização de um pino de cocaína em poder do acusado, em valoração probatória, tem-se que as provas produzidas em juízo não permitem concluir que a totalidade das drogas apreendidas pertencia ao réu, bem como não é possível concluir pela comercialização do entorpecente efetivamente apreendido com o acusado. Com efeito, os policiais não flagraram o acusado com a totalidade das drogas apreendidas, que estavam no interior de uma sacola escondida em um portão próximo, tampouco visualizaram comportamento que pudesse sugerir a traficância. Não localizaram com o acusado anotações características de tráfico, relevante quantia em dinheiro em notas trocadas, ou instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes.

Ao chegar ao palco dos fatos, o que os agentes públicos viram foi o acusado tentando se evadir, portando tão somente um pino de cocaína em seu bolso, o que é compatível com a versão defensiva. O que vincula o réu aos entorpecentes encontrados é apenas a suposta confissão informal do acusado. E assim teria feito tão apenas após a localização da sacola próxima em que as drogas estavam escondidas, sem qualquer auxílio do acusado neste ponto.

A par de ter que a confissão informal não seja meio de prova válido, até porque se trata de ato personalíssimo passível de retratação, não é, em princípio, crível que o réu tenha admitido tal fato no caso. Isto, pois seria também de se esperar que admitisse a prática delitiva na Delegacia de Polícia ou mesmo em Juízo. Não foi isso, no entanto, o que ocorreu.

Veja-se que, além da confissão informal, nada há mais nos autos que comprove a posse da totalidade dos entorpecentes apreendidos, o que autorizaria, por indução, concluir pelo exercício da traficância. Não há registro de realização campana ou qualquer outro ato investigativo.

Não se está desmerecendo o depoimento dado pelos policiais, mas para a condenação exige-se a prova contundente, que permita a formulação de juízo de certeza além de qualquer dúvida razoável. No caso, a confissão do acusado não ocorreu nem em solo policial nem em juízo, assim como apreendida com o acusado quantidade de entorpecente compatível com o uso. Não há outro meio de prova que o vincule à sacola oculta em lugar próximo e o acusado. Repita-se, não houve a realização de qualquer diligência que pudesse relacioná-lo à traficância.

Assim, não há elementos suficientes que permitam afirmar um juízo de certeza quanto aos termos da imputação inicialmente dada pelo Ministério Público.

O que se tem, reconheça-se, é um juízo de probabilidade de envolvimento do acusado com o comércio de drogas. No entanto, a afirmação da responsabilidade penal exige mais do que a mera probabilidade. Esta, como é sabido, ampara o oferecimento da ação penal. A afirmação da culpa, no entanto, supõe o afastamento do manto protetivo dado pela presunção da inocência o que, por sua vez, exige um quadro de certeza fundado nas provas obtidas. No presente caso, muito embora os elementos objetivos confirmem o selo da probabilidade de autoria, não é este suficiente para a declaração de procedência da pretensão punitiva. Nesse cenário, qualquer afirmação que implique o reconhecimento da figura penal do tráfico haveria de partir, necessariamente, de uma forte dose de presunção que, como se sabe, não se mostra cabível no contexto do Direito Penal.

Imperiosa, portanto, a readequação penal típica dos fatos para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Destaco que desnecessário o aditamento da denúncia na hipótese, pois o fato naturalístico imputado não é diverso.

Neste ponto, em que pese interpretação literal do disposto no art. 48, §1º da Lei n. 11.343/06 ("o agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais"), tenho que após a instrução do feito e a análise do mérito, não é o caso de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. Trata-se, em verdade, de prorrogação da competência, fixada pela capitulação inicial e processamento do feito, tudo como autorizado pelo artigo 74, § 2º, do Código de Processo Penal.

Neste sentido: Tráfico de entorpecentes. Sentença desclassificando a conduta do réu para a prevista no artigo 28, da Lei nº 11.3343/06, sem a devida aplicação da pena. Ordem de remessa ao Juizado Especial Criminal. Hipótese em que a E. Magistrada, entendendo que a hipótese não era de tráfico, mas de uso, deveria ter aplicado a reprimenda que entendesse cabível. Competência definida pela denúncia originalmente aceita. Sentença anulada de ofício. (TJSP; Apelação Criminal 0069613-98.2016.8.26.0050; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 13/07/2022).

Quanto ao reconhecimento da atipicidade da conduta e inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, tenho que enquanto a discussão no RE nº 635659/SP, com repercussão geral reconhecida, não for decidida em definitivo, deve prevalecer a constitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Verifico, por outro lado, que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente no crime de tráfico de drogas. Em razão disso não faz o réu jus aos benefícios da Lei 9.099/95, de forma que passo à dosimetria da pena

Considerando o histórico criminal do acusado apenas a condenação a pena de advertência não se mostra razoável. Sendo assim, fixo a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de três meses, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 11.343/06.

Assim, julgo parcialmente procedente o pedido condenatório para o fim de condenar o acusado RAFAEL MATOS FLAVIO, devidamente qualificado nos autos, como incurso no crime tipificado pelo artigo 28, da Lei 11.343/06 e aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo período de três meses, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 11.343/06.

Considerando as penas ao final impostas, desnecessária a manutenção da prisão preventiva. Assim, revogo a prisão preventiva imposta nestes autos. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Defiro a incineração da droga apreendida, com as cautelas da lei, nos termos do artigo 72 da Lei nº. 11.343/06, oficiando-se ao D. Delegado de Polícia para as providências cabíveis, reservando-se quantidade suficiente para contraprova. Observe-se os arts. 524 a 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Com relação à quantia em dinheiro apreendida, evidente a sua vinculação com o tráfico. Determino o seu perdimento em favor da União. Oficie-se, observado o Comunicado CG Nº. 805/2019.

Condene ainda o acusado ao pagamento das custas processuais.

Com relação aos demais objetos apreendidos, aguarde-se por 90 dias manifestação da

parte interessada.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, bem como demais ofícios necessários. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Ademais, revogado o artigo 393, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Santa Isabel, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA